

1500210-95.2020.8.26.0415

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/05/2022

... drogas em sua residência para fins de tráfico e, no dia dos fatos, postou-se em frente do imóvel para venda dos entorpecentes acima descritos.

Consta que policiais militares vinham recebendo denúncias anônimas de que KAUAN estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual estava em curso, nas imediações, patrulhamento policial que redundou na abordagem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

1500210-95.2020.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500210-95.2020.8.26.0415

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN VITOR LIBORIO DA SILVA

Juíza Substituta: Dr(a). LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA

Vistos.

KAUAN VITOR LIBORIO DA SILVA foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19 de maio de 2020, por volta das 16h15min, na Rua Pedro Elias, n.º 492, nesta cidade e Comarca de Palmital, o denunciado trazia consigo drogas, consistentes em 2 (duas) porções de maconha, e guardava mais 21 (vinte e uma) porções do mesmo entorpecente, com peso aproximado total de 341,54g, e 95 (noventa e cinco) porções de crack, com peso aproximado de 31,57g (cf. auto de constatação de fls. 24/25, laudo definitivo de fls. 78/80 e auto de exibição e apreensão de fls. 05/06), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia a seguinte narrativa:

"Segundo o apurado, o denunciado armazenava drogas em sua residência para fins de tráfico e, no dia dos fatos, postou-se em frente do imóvel para venda dos entorpecentes acima descritos.

Consta que policiais militares vinham recebendo denúncias anônimas de que KAUAN estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual estava em curso, nas imediações, patrulhamento policial que redundou na abordagem do denunciado.

Em revista pessoal, o denunciado foi flagrado na posse de duas porções grandes de maconha.

Dando sequência à diligência, após o denunciado franquear o ingresso no imóvel, os

policiais revistaram seu interior e nele localizaram mais de duas dezenas de porções de maconha, quase uma centena de "pedras" de crack, 1 (uma) balança de precisão e R\$ 292,85 em dinheiro.

As circunstâncias da prisão, as notícias anônimas anteriores e a grande quantidade e natureza das drogas demonstram que o denunciado utilizava o local para a prática do delito ora imputado."

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação às fls. 122/124.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2021 às fls.127/128.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha referida, bem como interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da presente ação e opinou pela aplicação da pena acima do mínimo legal, bem como pela fixação do regime fechado. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4, da Lei de Drogas e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e/ou fixação do regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Pois bem.

Respeitada a manifestação ministerial, o caso é de absolvição, porquanto ilícito o ingresso no domicílio do acusado, conforme passo a expor.

A testemunha Anderson Carlos de Oliveira, Policial Militar, disse: "havia várias denúncias de tráfico de drogas no local; quando chegaram ao local, ele estava defronte à residência; foi abordado, estando com ele as porções de drogas; indagado, ele confessou que havia mais drogas na casa; salvo engano, o resto das drogas estavam no congelador; foi encontrada balança de precisão; havia denúncias da traficância; já abordou o acusado; não sabe de outras ocorrências envolvendo droga ou tráfico; o acusado não estava sob efeito da droga; o acusado admitiu a venda das drogas." Ao final, aos esclarecimentos do Juízo, disse: "a busca pessoal foi realizada sob fundada suspeita, pois quando viu a equipe, ele ficou bastante nervoso; o acusado estava próximo da sua residência."

A testemunha José Roberto de Araújo, Policial Militar, disse: "participou da ocorrência; receberam uma denúncia anônima; ao se dirigir até o local, encontraram o acusado; o acusado foi abordado; com o acusado foram encontradas duas porções de maconha; perguntado, ele assumiu a propriedade da droga; falou que estava vindo do horto florestal, local em que havia adquirido as drogas; acusado disse ainda que havia mais drogas na residência; logo após autorizado, entraram na residência e localizaram o restante das drogas; havia diversas denúncias; o acusado não demonstrava estar sob efeito de drogas." Às perguntas da defesa, disse: "foram encontradas duas porções; segundo informações prestadas pelo acusado, este estava voltando das proximidades do horto, onde foi buscar as drogas; naquele momento, as drogas seriam tão somente aquelas duas porções."

O acusado Kauan, na fase policial, disse que: "deseja apenas dizer que sua esposa

não possuía qualquer envolvimento com as drogas e no mais deseja exercer seu direito constitucional de ficar em silêncio."

Em juízo, disse que: "os fatos não são verdadeiros; realmente vendia droga; não estava vindo do horto, mas de uma padaria; sua mulher ligou e falou para vir até a casa, pois os policiais estavam lá; falou para os policiais não relarem na sua esposa, pois já estava indo se entregar; chegou e já se entregou; quem falou com ele foi o Policial Roberto." Às perguntas do Ministério Público, disse; "que não fazia nem dois dias que estava com a droga; começou a vender droga com 18 anos; não faz nem um ano que vendia; trabalhava e começou a vender droga depois que foi mandado embora; fazia mais de seis meses que estava vendendo; estava vendendo crack também." Ao final, aos esclarecimentos do Juízo, disse: "que não usa drogas; sua esposa se chama Maria Zilda de Oliveira."

A testemunha referida, Maria Zilda de Oliveira, disse: "que policiais chegaram na sua residência; ligou para o acusado subir até o local; os policiais localizaram as drogas; o acusado subiu e se entregou." Às perguntas do Ministério Público, disse: "as drogas estavam dentro da sua casa; no quarto era seu; o acusado falou que a droga era dele." Ao final, aos esclarecimentos do Juízo, disse: "que o acusado não estava em casa, nem na frente."

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório não se presta a responsabilizar o acusado pela prática do delito descrito na denúncia, já que os depoimentos prestados em juízo foram antagônicos, havendo severas dúvidas, não só sobre a apreensão de duas porções de maconha, mas, especialmente, acerca da legalidade do ingresso dos Policiais Militares na residência do acusado.

Logo, havendo dúvida, esta deve favorecer a defesa.

Conforme previsão estampada no art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Logo, conclui-se que o ingresso no domicílio do acusado poderia ser admitido em três situações, são elas: i) se houvesse autorização judicial para tanto; ii) se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador; e iii) se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência e flagrante delito no local e a urgência não permitisse a espera por mandado judicial.

In casu, a primeira hipótese é claramente inexistente. Da mesma forma, também não há falar na existência de fundadas razões prévias da existência de drogas da casa, posto que, como já dito, há fundadas suspeitas de que o acusado sequer estava na frente da sua casa. Por sua vez, em decorrência lógica da suspeita apontada, sequer há como considerar como válida a suposta autorização do acusado no caso em tela. Ora, enquanto os Policiais Militares apontam que o acusado estava defronte à sua residência, tanto a testemunha referida quanto o próprio acusado falaram o contrário.

De mais a mais, ainda que sejam verdadeiros os fatos tal como narrados pelos policiais, a questão que se coloca é por que alguém que guarda objetos ilícitos que podem lhe custar até 15 anos de prisão consentiria com a entrada da polícia em sua casa para realização de busca, senão pelo desconhecimento do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ou pelo temor do que poderia resultar de sua negativa, isto é, pela falta de condições concretas de negar, ainda que não haja coação direta por parte dos agentes policiais.

Não se cuida aqui de desmerecer a valorosa e honrosa atividade policial ou de presumir a prática de coações por parte dos policiais. Não é isso. O que se pondera, contudo, é a impossibilidade de que provas obtidas por meio ilegais justifiquem a prolação de uma sentença condenatória em desfavor do acusado.

Não se desconhece a grande quantidade de drogas apreendidas, a forma que estavam embaladas e, até mesmo, a existência de balança de precisão, mas o fato é que toda a cadeia de provas restou prejudicada a partir do momento em que não há como ter a certeza de que o acusado estava realmente defronte à sua residência e, de forma livre e sem vício de consentimento, autorizou o ingresso dos policiais na sua vivenda.

Sobre o tema, a jurisprudência da 5ª e da 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça

estabeleceu balizas para a análise de situações como a que ora se apresenta:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação amiúde irreversível de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de

justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. [...]

6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/T0). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial ao dispor que, “[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º”. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação como ocorreu no caso ora em julgamento de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. [...]. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria

autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. [...] (HC 628.371/SC,

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) – grifos acrescentados

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e conseqüentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). [...] (HC 616.584/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021) – grifos acrescentados

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, ABSOLVO DOUGLAS HENRIQUE DE MORAES FREITAS, filho de pai Paulo Celso da Silva, mãe Valdira Liborio de Moraes e portador do RG nº 56.735.824-0/SP, das acusações a ele imputadas na denúncia, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários a defensora nomeada, no máximo previsto na Tabela respectiva para esta classe processual. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações necessárias e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Palmital, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA